

1503480-21.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.

II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503480-21.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503480-21.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287226/2021 - DEL.POL.GUARUJA, 20943655 -

DEL.POL.GUARUJA, 2287226 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS DE LIMA PEREIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Nicolas de Lima Pereira, Gustavo Henrique Santos e Daniel Ribeiro da Silva, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no crime do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal, porque, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 17:10 horas, na Viela Santo Amaro, Comunidade do Caranguejo, Cachoeira, nesta cidade e comarca de Guarujá, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, com o adolescente W.B.S.S., nascido em 16 de novembro de 2003, e com um quinto agente não identificado, durante a pandemia de Covid-19, em ocasião de calamidade pública, tinham em depósito e guardavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em diversas porções de

Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, totalizando cerca de 53 Kg (cinquenta e três quilos); de diversas porções de cocaína, totalizando cerca de 4,8 Kg (quatro quilos e oitocentos gramas), e de uma pedra de crack, derivada da cocaína, com peso de cerca de 25 g (vinte e cinco gramas), substâncias ilícitas que determinam dependência física e psíquica, consoante o auto de constatação preliminar de fls. 47/48, o auto de exibição e apreensão de fls. 52/54 e as fotografias de fls. 56/71, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante do réu Daniel Ribeiro da Silva foi convertida em prisão preventiva, e aos réus Nicolas de Lima Pereira e Gustavo Henrique Santos foi concedido o benefício da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares (fls. 102/105). No entanto, não obstante a respeitável decisão do juízo de custódia, este juízo entendeu presentes os requisitos autorizadores e decretou a prisão preventiva de Nicolas de Lima Pereira e Gustavo Henrique Santos (fls. 149/150), encontrando-se os mandados de prisão pendentes de cumprimento (151/153, 154/156).

Os acusados foram notificados e apresentaram defesas prévias (231/232, 341/343, 352, 354), que não comportaram acolhimento. A denúncia foi recebida e os réus citados (fls. 274/275, 356, 362, 370, 420).

Foi juntado aos autos o laudo de exame químico-toxicológico realizado nas drogas apreendidas (fls. 167/173).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu Daniel Ribeiro da Silva foi interrogado (fls. 386/387). A instrução foi declarada encerrada e o representante do Ministério Público nada requereu, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. A defesa do réu Daniel, no entanto, requereu cópia da gravação da abordagem dos acusados - imagens captadas por câmera utilizada pelo policial militar Juscelino Marcos dos Santos, na data dos fatos - o que foi deferido (fls. 382) e juntado aos autos o link de acesso às imagens captadas pela câmera utilizada pelo policial militar (fls. 392).

O representante do Ministério Público, nos memoriais, requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, entendendo que a autoria e a materialidade do delito restaram provadas durante a instrução criminal (fls. 396/413).

Nos memoriais, a defesa constituída dos réus Nicolas de Lima Pereira e Gustavo Henrique Santos requereu, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, pois o juízo não autorizou que ambos os acusados, foragidos da Justiça, participassem da audiência virtual e fossem interrogados. No mérito, requereu a improcedência da ação com a absolvição dos réus, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação das atenuantes da confissão na fase extrajudicial e da menoridade - para ambos os acusados - a aplicação da Tese 712 do STF, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06 - com a redução no patamar máximo, de 2/3 - a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão aos réus do direito de apelar em liberdade (fls. 422/427).

A defesa do réu Daniel Ribeiro da Silva, nos memoriais, reiterou o requerimento de juntada aos autos da gravação feita por um dos policiais que participou da prisão dos acusados. O julgamento foi convertido em diligência para intimar a defesa de que o link de acesso às imagens já se encontrava acostado aos autos, às fls. 392. E manifestou-se a combativa defesa, às fls. 451, reiterando os memoriais de fls. 437/441. Requereu a absolvição do réu Daniel Ribeiro pela fragilidade do conjunto probatório; todavia, se diverso o entendimento, requereu o reconhecimento da nulidade do processo, considerando que todas as provas foram obtidas a partir da violação de domicílio dos acusados, devendo ser consideradas ilícitas. Requereu, também, a apuração do crime de abuso de autoridade, com a remessa à autoridade policial competente das peças processuais necessárias. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela aplicação do redutor e da fixação do regime prisional inicial aberto (fls. 437/441, 451).

É o relatório.

Decido.

A preliminar suscitada pela defesa dos réus Nicolas de Lima Pereira e Gustavo Henrique Santos não comporta acolhimento.

Não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante a não autorização do juízo para que ambos os réus, foragidos da Justiça, participassem da audiência virtual e fossem interrogados.

No caso dos autos, verifica-se que foi decretada a prisão preventiva dos acusados Nicolas e Gustavo (fls. 149/150) e ambos permanecem foragidos, de modo que renunciaram, tacitamente, ao direito de participação de todos os atos instrutórios, inclusive de seus interrogatórios.

Neste sentido, a jurisprudência:

"PROCESSO PENAL. Denúncia por latrocínio. Audiência de instrução virtual. Pleito defensivo deferido pelo juízo processante para que um dos réus, foragido e com prisão preventiva decretada, acompanhasse a audiência por videoconferência.

Insurgência ministerial para impedir igual procedimento na audiência subsequente, designada para o dia 23 de outubro próximo futuro. Participação incompatível com a condição de foragido. Interesse sequer albergado pelo direito à ampla defesa, que não é absoluto e tampouco se sobrepõe à sistemática processual penal. Renúncia tácita ao direito de participar ou mesmo acompanhar os atos instrutórios.

Deferimento da correição parcial para obstar a participação virtual do réu foragido na audiência designada para a continuidade da instrução." (TJSP; Correição Parcial Criminal nº 2188428-34.2020.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; j. 19/10/2020; v.u.)

De igual modo, a preliminar suscitada pela defesa do réu Daniel Ribeiro da Silva não comporta acolhimento.

Não há que se falar em nulidade das provas dos autos em razão da suposta invasão de domicílio pelos policiais militares que participaram da operação.

No caso dos autos, havia situação de flagrante delito, uma vez que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades ter em depósito e guardar são de natureza permanente. Portanto, havia permissão constitucional para que os policiais adentrassem no imóvel do local dos fatos sem o respectivo mandado judicial.

Neste sentido, a jurisprudência:

"I - É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.

II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo que se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrido, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses [...]" (STJ - AgRg no HC 656042 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 25/05/2021, DJe 04/06/2021).

Assim, não há que se falar em invasão de domicílio, porquanto o estado de flagrância autoriza que os agentes policiais ingressem em qualquer local para efetuar a prisão.

Cabe mencionar, ainda, que os policiais militares relataram em juízo que se tratava de barraco desabitado, utilizado exclusivamente como "laboratório" dos traficantes, o qual continha em seu interior tão somente a mesa utilizada para pesagem e embalagem das drogas, o que foi confirmado pelas imagens captadas pela câmera utilizada por um dos policiais militares, conforme link juntado a fls. 392. No momento da abordagem policial, a janela e a porta do barraco encontravam-se abertas, o que possibilitou aos policiais a visualização das drogas sobre a mesa e os acusados ao redor da mesa, pesando-as e embalando-as.

Assim, não há que se falar em nulidade das provas colhidas, restando afastadas as preliminares suscitadas por ambas as defesas.

Passo à análise do mérito.

Em relação ao mérito, a ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em

flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 03/11, pelo auto de constatação preliminar de fls. 47/48, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 52/54, pelas fotografias de fls. 56/71, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 167/173 e 216/222, pelos laudos periciais de fls. 223/224, 237/239, pelo link com as imagens da abordagem dos réus - juntado às fls. 392, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria dos réus também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Na fase extrajudicial, o acusado Nicolas de Lima Pereira foi cientificado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e assim o fez, quando de seu interrogatório (fls. 16).

Em juízo, o acusado Nicolas não foi interrogado, uma vez que se encontra foragido, com mandado de prisão expedido em seu desfavor pendente de cumprimento (fls. 149/150, 151/153).

Na fase extrajudicial, ao ser interrogado, o acusado Gustavo Henrique Santos confessou a prática delitiva. Relatou que decidiu traficar para guardar dinheiro e comprar roupas. Sua função era na embalagem, e ganhava R\$ 50,00 (cinquenta reais) por dia. Quando foi abordado, estava há três dias traficando, e havia conseguido R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Acrescentou que todos os detidos estavam juntos no momento da abordagem policial (fls. 17).

Em juízo, o acusado Gustavo não foi interrogado, uma vez que se encontra foragido, com mandado de prisão expedido em seu desfavor pendente de cumprimento (fls. 149/150, 154/156).

Na fase extrajudicial, o acusado Daniel Ribeiro da Silva foi cientificado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e assim o fez, quando de seu interrogatório (fls. 18).

Em seu interrogatório judicial, Daniel negou a autoria delitiva. Relatou que na data dos fatos estava se dirigindo a um campeonato de futebol local, quando foi abordado pela Polícia que lhe fez perguntas a respeito de sua vida e eventual envolvimento com o crime, e também perguntou se o acusado sabia onde ficava o "barraco bomba" da favela, ao que respondeu negativamente o interrogando. Nesse momento, passaram viaturas para o interior da favela e um dos policiais que abordaram o acusado se comunicou por telefone com alguém, aparentemente com outro policial. E na sequência, os policiais da abordagem do interrogando receberam uma chamada com a informação "achamos, achamos, traz ele". Então, os policiais conduziram o interrogando para o "fundão" da favela, nas palafitas. Lá chegando, entraram em um barraco onde havia outras pessoas, uma delas algemada e deitada no chão, e o acusado ficou sem entender nada, muito assustado. Também havia uma mesa com quantidade elevada de drogas sobre ela. O interrogando enfatizou que não está envolvido no caso tratado nestes autos, sua abordagem foi em local diverso e os policiais o conduziram até o barraco da palafita, onde havia outras pessoas e as drogas apreendidas. O interrogando conhece os acusados, porque todos residem na mesma comunidade, mas não estava com eles no local dos fatos (fls. 386).

Entretanto, as provas produzidas nos autos demonstraram o inequívoco envolvimento dos acusados no tráfico drogas, e não foi apresentada situação capaz de excluir o crime ou isentá-los de pena.

Senão vejamos.

O policial militar Juscelino Marcos dos Santos, em seu depoimento judicial, relatou que na data dos fatos estava em patrulhamento na comunidade do Caranguejo, região das palafitas, que é conhecido ponto de tráfico de drogas. E quando a equipe se aproximou de um barraco de madeira, foi possível ver pela janela que havia alguns indivíduos em seu interior, e um dos indivíduos que lá estavam percebeu a chegada da Polícia. Então, aceleraram a marcha para evitar a fuga dos ocupantes do barraco. A porta se encontrava aberta e avistaram drogas sobre uma mesa. Os réus, o adolescente infrator e um quinto indivíduo não identificado estavam ao redor da mesa embalando as drogas. Havia cerca de 60 Kg de drogas no local dos fatos, algumas já embaladas sobre a mesa e porções em sacos, aguardando pesagem e embalagem. No local, também encontraram balança de precisão, facas, embalagens vazias, rádio comunicador, rolo de papel plástico. Não se recorda se encontraram

dinheiro. Não havia anotações. O depoente viu quando o quinto indivíduo pulou a janela do barraco. Todos receberam voz de prisão. O barraco onde os indivíduos foram detidos era conhecido no meio policial, de operações anteriores, por ser o local de embalagem de entorpecentes. O depoente, inclusive, já havia diligenciado nesse barraco, mas na ocasião não encontrou ninguém, somente alguns apetrechos e embalagens vazias. Na data dos fatos, a equipe deliberou por diligenciar nesse conhecido barraco novamente e obteve êxito. A diligência foi direcionada ao barraco. O depoente e seu colega não abordaram ninguém antes de chegarem ao barraco, palco dos fatos. Não foi requerido mandado judicial para entrar no barraco, porque se tratava de barraco abandonado, desabitado, já conhecido da Polícia por ser local de refino e embalagem de drogas. Entraram no barraco porque da porta foi possível avistar grande quantidade de drogas sobre a mesa e os indivíduos manuseando-as para a embalagem, configurando-se situação passível de prisão em flagrante. Os acusados e o adolescente infrator confessaram que estavam embalando as drogas. O depoente não se recorda se algum dos acusados informou quanto ganhava por dia para embalar as drogas. Após a detenção dos acusados, foi necessário acionar apoio para a condução de todos à Delegacia de Polícia. O depoente não conhecia os réus e o adolescente infrator anteriormente aos fatos. (fls. 386).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar Bruno Nunes Viana. A testemunha relatou que na data dos fatos se encontrava em patrulhamento com seu colega, o policial Juscelino Marcos, na comunidade do Caranguejo, e ao final da Viela do Caranguejo desembarcaram das motocicletas e seguiram a pé até a região das palafitas, conhecido ponto de tráfico de drogas. No local, quando se aproximaram de um barraco de madeira, que estava com a porta aberta, avistaram os réus, o adolescente infrator e o quinto indivíduo não identificado. Havia uma mesa nesse barraco e sobre ela grande quantidade de drogas. Os cinco indivíduos estavam ao redor dessa mesa, pesando e embalando as drogas. Então, deram voz de prisão aos ocupantes do barraco e o quinto indivíduo conseguiu se evadir. No local dos fatos, havia elevada quantidade de drogas, cerca de 60 Kg, consistentes em maconha, cocaína e crack. O depoente nunca havia ido a esse barraco especificamente, mas tinha conhecimento de que nas palafitas havia barraco utilizado como "laboratório". No barraco também havia balança de precisão, facas, papel filme, flaconetes, tesouras e outros objetos. O barraco era desabitado, nele só havia a mesa, as drogas e os apetrechos, nenhum móvel mais. A equipe não realizou abordagem antes ou depois da abordagem realizada no barraco. Após a detenção dos acusados, foi necessário acionar apoio para a condução de todos à Delegacia de Polícia. A operação foi gravada. O depoente não se recorda se algum dos acusados informou quanto ganhava por dia para embalar as drogas (fls. 386).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente os acusados da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, DJe. 30/10/2018).

"[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, [...]". (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Ainda, os depoimentos dos policiais militares foram confirmados pelas imagens captadas pela câmera utilizada por um dos policiais militares, conforme link juntado a fls. 392.

Ora, diante dos depoimentos dos policiais militares, que narraram de forma segura e

harmônica a conduta dos réus, ante a grande quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como do material apreendido no local (vários apetrechos utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas como balança de precisão, facas, papel filme, flaconetes, rádio comunicador, liquidificador), diante da confissão do acusado Gustavo Henrique Santos na fase extrajudicial (fls. 17), o qual afirmou que todos os acusados estavam juntos no local dos fatos, no momento da abordagem policial, sem dúvida, os entorpecentes apreendidos foram encontrados com os réus e eram destinados para o consumo de terceiros, ou seja, para a venda. Pelas imagens fornecidas pelo link de fls. 392, constata-se que os réus estavam juntos no local dos fatos e resta evidente que os réus estavam embalando drogas no local. As imagens também revelaram que o local era utilizado unicamente para a manipulação de drogas destinadas para a venda, apresentava apenas uma mesa e vários apetrechos para a manipulação das drogas e sua preparação para a venda.

Ainda, a versão do réu Daniel Ribeiro da Silva de que primeiro foi abordado pelos policiais militares, em local diverso do local dos fatos, e posteriormente conduzido até o barraco onde se encontravam as drogas, não foi comprovada nos autos por qualquer elemento de prova e foi afastada pelas imagens captadas pela câmera utilizada pelo policial militar.

Portanto, não há como afastar a responsabilidade criminal dos acusados, prevalecendo, pois, a tipicidade de suas condutas.

Diante das provas produzidas, a autoria do delito é indiscutível. É certo que os acusados tinham em depósito e guardavam diversas porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, totalizando cerca de 53 Kg (cinquenta e três quilos); diversas porções de cocaína, totalizando cerca de 4,8 Kg (quatro quilos e oitocentos gramas), e uma pedra de crack, derivado da cocaína, com peso de cerca de 25 g (vinte e cinco gramas), e os entorpecentes eram destinados à venda e ao consumo de terceiros, ante as condutas dos acusados narradas pelos policiais militares que fizeram a abordagem e a prisão em flagrante dos acusados. Destaque-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

Por fim, o crime de tráfico imputado aos réus restou consumado, uma vez evidenciado que os entorpecentes apreendidos com os réus eram destinados à venda para o consumo de terceiros.

Definidas as condutas dos réus, passo à dosimetria da pena.

Para os réus Nicolas e Gustavo:

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a variedade e a grande quantidade dos entorpecentes apreendidos, destacando que a cocaína tem alto poder viciante, entendo que a conduta dos réus revestiu-se de reprovabilidade excepcional, pois atingiria inúmeras pessoas, de forma que elevo em 1/6 a pena-base, perfazendo em: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a pena permanece inalterada. Deixo de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. No caso dos autos, verifica-se que o estado de calamidade, em vigência desde o dia 20 de março de 2020 após a publicação do Decreto Legislativo nº 6/2020, em razão da pandemia de Covid-19, em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito. Para a configuração da agravante, deve, pois, existir nexos entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva. E, no caso dos autos, não restou comprovada a presença de qualquer facilidade para o cometimento do delito decorrente da situação de calamidade.

Ainda na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade dos acusados, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, e reduzo a pena em 1/6, perfazendo em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Destaco que a atenuante não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal. E pela mesma razão deixo de reduzir a pena pela confissão espontânea do réu Gustavo na fase extrajudicial.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da

Lei nº 11.343/2006, elevo a pena em 1/6, perfazendo a reprimenda o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, ainda, entendo não ser o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, para sua aplicação, além do preenchimento dos requisitos estabelecidos no tipo penal (agente primário e de bons antecedentes), deve ficar demonstrado que o réu não se dedica a atividade criminosa nem integra organização criminosa, ou seja, deve ficar demonstrado que o réu agiu de forma ocasional. Tem-se que a intenção do legislador, ao permitir a redução das sanções penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele eventual. No caso dos autos, os réus Nicolas e Gustavo apresentam a condição de primários e não possuem antecedentes (fls. 76/77, 80/81); todavia, o contexto fático-probatório demonstrou que se trata de modus operandi de quem se dedica com habitualidade à atividade criminosa, dela fazendo um meio de vida. Foram encontradas no barraco, local dos fatos, porções individualizadas de entorpecentes prontas para a venda e entorpecente a granel, além de balança de precisão, rádio de comunicação, peneira, faca, rolo de filme plástico, telefones celulares, e o valor de R\$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, o que demonstra a habitualidade da conduta ilícita e impõe o afastamento da benesse. Torno definitiva a pena aplicada.

Para o réu Daniel:

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a variedade e a grande quantidade dos entorpecentes apreendidos, destacando que a cocaína tem alto poder viciante, entendo que a conduta do réu revestiu-se de reprovabilidade excepcional, pois atingiria inúmeras pessoas, de forma que elevo em 1/6 a pena-base, perfazendo em: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ante a reincidência do réu (Processo nº 0000029-72.2015.8.26.0536, fl. 78) elevo a pena em 1/6, perfazendo a reprimenda o montante de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na segunda fase, ainda, a pena permanece inalterada. Deixo de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. No caso dos autos, verifica-se que o estado de calamidade, em vigência desde o dia 20 de março de 2020 após a publicação do Decreto Legislativo nº 6/2020, em razão da pandemia de Covid-19, em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito. Para a configuração da agravante, deve, pois, existir nexos entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva. E, no caso dos autos, não restou comprovada a presença de qualquer facilidade para o cometimento do delito decorrente da situação de calamidade.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006, elevo a pena em 1/6, perfazendo a reprimenda o montante de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Na terceira fase, ainda, entendo não ser o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, para sua aplicação, além do preenchimento dos requisitos estabelecidos no tipo penal (agente primário e de bons antecedentes), deve ficar demonstrado que o réu não se dedica a atividade criminosa nem integra organização criminosa, ou seja, deve ficar demonstrado que o réu agiu de forma ocasional. Tem-se que a intenção do legislador, ao permitir a redução das sanções penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele eventual. No caso dos autos, o réu Daniel é reincidente, apresentando condenação por crime de roubo circunstanciado e corrupção de menores (fls. 78/79). O contexto fático-probatório e o histórico criminal do acusado Daniel evidenciam que se trata de agente que se dedica com habitualidade a atividade criminosa, dela fazendo um meio de vida. Ainda, foram encontradas no barraco, local dos fatos, porções individualizadas de entorpecentes prontas para a

venda e entorpecente a granel, além de balança de precisão, rádio de comunicação, peneira, faca, rolo de filme plástico, telefones celulares, e o valor de R\$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, o que confirma a habitualidade da conduta ilícita e impõe o afastamento da benesse.

Torno definitiva a pena aplicada.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida por todos os réus inicialmente em regime fechado, por entender que se trata do regime prisional que se amolda às condutas dos acusados, que demonstraram se dedicar a atividade criminosa.

Ainda, considerando as penas aplicadas, bem como a gravidade do delito, não são cabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou da suspensão condicional da pena - nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Por fim, eventual progressão de regime será apreciada oportunamente pelo juízo da execução. Destaco que as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2º, ao artigo 387 do Código de Processo Penal, não revogaram os dispositivos da Lei de Execução Penal, que devem ser considerados para a progressão de regime prisional. Logo, para a progressão de regime não basta apenas a consideração do tempo de prisão provisória - embora no caso dos autos os réus ainda não tenham cumprido o requisito temporal, objetivo - devendo ser preenchidos os demais requisitos legais dispostos na Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra os réus para CONDENAR Nicolas de Lima Pereira e Gustavo Henrique Santos à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal, por incursos nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal. E para CONDENAR Daniel Ribeiro da Silva à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa no valor unitário do mínimo legal, por incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal.

Os acusados não poderão apelar em liberdade. Trata-se do grave crime de tráfico de drogas, hediondo por equiparação, que traz consequências nefastas à sociedade. O réu Daniel Ribeiro da Silva apresenta a condição de reincidente pela prática do crime de roubo circunstanciado e corrupção de menores (fls. 78), demonstrando periculosidade concreta, e que em liberdade poderá tornar a praticar condutas ilícitas e não ser encontrado para a aplicação da presente decisão, tornando-a inócua. Em relação aos réus Nicolas de Lima Pereira e Gustavo Henrique Santos, sem antecedentes e primários, encontram-se foragidos, evidenciando, assim, que colocam em risco a aplicação da lei penal. Primariedade não autoriza a revogação da prisão preventiva de ambos, em se tratando do grave crime de tráfico ilícito de drogas, quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual também não poderão recorrer em liberdade, ficando mantida a decretação da prisão preventiva dos réus.

Logo, recomende-se o réu Daniel Ribeiro da Silva na prisão em que se encontrar, e aguarde-se o cumprimento dos mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor dos réus Nicolas de Lima Pereira e Gustavo Henrique Santos (fls. 151/153, 154/156).

Nos termos da Lei nº 11.343/2006, após o trânsito em julgado, oficie-se à autoridade policial competente requisitando a incineração da porção das drogas reservada para eventual contraprova.

Resta indeferido o requerimento da defesa do réu Daniel Ribeiro da Silva de envio à autoridade policial de cópias dos autos processuais para a apuração do crime de abuso de autoridade - por parte dos policiais que participaram da operação. Os policiais militares que atenderam a ocorrência agiram com permissão constitucional, inexistindo qualquer irregularidade a ser reconhecida nos procedimentos. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades ter em depósito e guardar, é crime permanente, e



antes do ingresso no barraco, que sequer era habitado, os policiais avistaram os réus e o quinto indivíduo, não identificado, manipulando os entorpecentes em volta de uma mesa. Portanto, havia situação concreta de flagrante delito que legitimava o ingresso dos agentes públicos no local dos fatos, sem a necessidade de mandado judicial.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União, uma vez que se trata de produto do tráfico de drogas e determino a destruição de todos os objetos elencados às fls. 52/54, pois instrumentos utilizados para o narcotráfico. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para cumprimento.

No que tange às custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público Estadual ao réu Daniel Ribeiro da Silva, tem-se que foi deferida tacitamente a assistência judiciária gratuita. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/1950.

E em relação aos réus Nicolas de Lima Pereira e Gustavo Henrique Santos, defiro a gratuidade da Justiça requerida, ante as declarações de pobreza, na acepção jurídica do termo, apresentadas às fls. 353, 355.

P.I.C.

Guaruja, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA